

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS XV

Vamos seguir falando sobre os direitos e as garantias fundamentais, mas vamos começar por um ponto que não está explicitamente previsto na Constituição Federal/88: princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade também regem a Administração Pública; no entanto, não estão previstos no artigo 37 da CF/88.

Na Lei n. 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo), há previsão expressa dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Esses princípios não estão de modo explícito na Constituição Federal, mas sim de maneira implícita.

A solução para a coalisão entre direitos fundamentais é feita por meio da ponderação de interesses no caso concreto. Dentro dessa ponderação de interesses, teremos o valor dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Há diferença entre razoabilidade e proporcionalidade: a proporcionalidade vem do direito alemão, enquanto a razoabilidade vem dos Estados Unidos.

Para muitos doutrinadores, a razoabilidade e a proporcionalidade são encaradas como sinônimos.

Em relação à proporcionalidade, alguns doutrinadores dizem que é uma regra, conforme leciona Bernardo Gonçalves Fernandes. Por outro lado, há doutrinadores que entendem que é um princípio, e, ainda, para outros doutrinadores, não seria regra ou princípio, mas sim um postulado. O postulado está acima de regras e princípios, conforme ensina Humberto D'Ávila.

Obs.: | Para a sua prova, responda no sentido de que é um princípio.

Embora parte da doutrina, entenda que a razoabilidade e a proporcionalidade são sinônimas.

A proporcionalidade possui 03 (três) subprincípios:

- Adequação;
- Necessidade;
- Proporcionalidade em sentido estrito.

É como se a norma, para ser válida, tivesse de passar por alguns filtros.

Vale destacar que, alguns anos atrás, foi publicada uma lei estadual que proibia a venda de artigos de conveniência em farmácias e drogarias. A lógica era evitar a automedicação. Por exemplo, a pessoa entraria na drogaria para comprar um picolé e já aproveitaria para levar um medicamento para dores. O STF entendeu que realmente é necessário evitar a automedicação, mas proibir a venda de artigos de conveniência dentro da drogaria, por si só, não vai evitar a automedicação. Assim, não é a ferramenta adequada para impedir a automedicação, sendo mais adequadas campanhas de conscientização da população. Logo, a lei foi declarada inconstitucional.

Por exemplo, a venda de um celular usado por trinta mil reais e um relógio original por trinta reais. Repare que valores são desproporcionais para mais ou para menos.

Dessa forma, a proporcionalidade ainda tem o viés para mais e para menos. No viés para mais, é chamado de proibição de excesso; enquanto no viés para menos é denominado de proibição de proteção insuficiente ou deficiente.

Exemplo: ao tipificar uma conduta como criminosa, se a pena for muito alta, será desproporcional e, se for muito baixa, não protegerá o bem jurídico tutelado.

A doutrina diz que a proporcionalidade no sentido estrito é a mesma coisa de razoabilidade. Assim, a razoabilidade seria um dos três subprincípios.

Logo, dentro dessa lógica, a proporcionalidade teria como subprincípios a adequação, a necessidade e a razoabilidade.

Vamos retornar à análise dos dispositivos do artigo 5º da Constituição Federal/88.

DA EXTRADIÇÃO

LI – nenhum brasileiro será **extraditado**, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LII – não será concedida **extradição** de estrangeiro por crime político ou de opinião.

O brasileiro nato está no topo da pirâmide: nenhum brasileiro nato pode ser extraditado pelo Brasil, podendo ser extraditado PARA o Brasil.

Por outro lado, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas situações: i) crime cometido antes da naturalização; ii) envolvimento comprovado com o tráfico de drogas, antes ou depois da naturalização. O único delito que permite a extradição após a naturalização é o tráfico de drogas.

O estrangeiro não pode ser extraditado no caso de crime político ou de opinião. Em outras palavras, se não for crime político ou de opinião, o Brasil pode extraditar o estrangeiro.

Vale lembrar que a Emenda à Constituição n. 131/2023 trouxe profundas modificações na sistemática relativa à perda da nacionalidade. Agora, a extradição que aconteceu no “caso Cláudia” não pode mais acontecer.



5m



10m

Contextualizando, alguns anos atrás, uma brasileira nata foi para os Estados Unidos e, chegando lá, ganhou o *greencard*. Depois de um tempo, ela se submeteu ao processo e se naturalizou voluntariamente norte-americana. Ocorre que ela matou o marido, ex-fuzileiro, e retornou ao Brasil. Os EUA solicitaram ao Brasil a extradição, e o Brasil concedeu, sob o argumento de que, quando voluntariamente pediu a nacionalidade americana, perdeu a nacionalidade brasileira e, portanto, poderia ser extraditada.

A Emenda à Constituição n. 131/2023 prevê que não há perda da nacionalidade brasileira quando é adquirida outra nacionalidade. O brasileiro nato somente perderá a nacionalidade se pedir expressamente que não mais quer ser brasileiro, somente sendo aceito caso já tenha outra nacionalidade. Não é possível renunciar a nacionalidade brasileira e se tornar apátrida (no texto constitucional, está “ressalvadas as situações de apatridia”).

Importante destacar:

- Não pode extraditar aquele que possui dupla nacionalidade nata. Por exemplo, aquele que é italiano nato e brasileiro nato. O Brasil não admite a tese da nacionalidade prevalente.
- O banimento é a expulsão de brasileiro do território nacional, o que é proibido. A expulsão é permitida daquele que está no território brasileiro e pratica alguma violação. A extradição é o pedido formulado por outro país para que entregue o agente a ele.

Caso Robinho: condenado por delito sexual ocorrido na Itália; contudo, não pode ser extraditado. Ele poderá responder pelo delito aqui no Brasil, inclusive ser obrigado a cumprir a pena aqui, mediante requerimento. A pena será a mesma.

- A pessoa que possui família brasileira não pode ser expulsa, porém pode ser extraditada.
- É possível a extradição ativa, mas não é possível a extradição passiva. A extradição passiva consiste no Brasil enviar o cidadão nato. Por outro lado, a extradição ativa é o recebimento de brasileiro nato. Caso do banqueiro Salvatore Cacciola: estava preso, o STF proferiu decisão o soltando e no dia seguinte ele foi embora para a Itália. Revogaram a liminar e pediram a extradição; contudo, ele era brasileiro e italiano nato. Cacciola foi passear em Mônaco, um principado, a lista da interpol o identificou e extraditou o brasileiro nato. Possibilidade de extradição de brasileiro nato.

PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E DO JUIZ NATURAL

LIII – ninguém será **processado nem sentenciado** senão pela autoridade competente.

Vale destacar que: ninguém será PROCESSADO = promotor natural; ninguém será JULGADO = juiz natural.

O princípio do juiz natural aparece mais de uma vez no artigo 5º da CF/88 quando disciplina que não haverá juízes ou tribunais de exceção (tribunal criado após o fato para julgar o próprio fato).

Acerca do tribunal de exceção, vemos na história, com o final da 2ª Guerra Mundial, em que os países da Alemanha e Japão saíram derrotados. Com isso, foram criados o Tribunal de Nuremberg e o de Tribunal de Tóquio para julgar os crimes desses países.

A Convenção da ONU de 1948 proibiu a figura do tribunal de exceção.

Repare que, no julgamento de um governador, por exemplo, Witzel, governador do RJ, foi adotado o procedimento do Tribunal Especial previsto na lei n. 1.079/50, no qual o julgamento contava com 5 deputados, 5 desembargadores e o presidente do Tribunal de Justiça. Não é um Tribunal de Exceção, a mera escolha da composição dos membros e não é um tribunal permanente.

Existe o princípio do defensor natural? SIM, embora não esteja previsto na Constituição Federal/88. A Lei Complementar 80/94, lei do defensor público, prevê o princípio do defensor público natural.



20m

DA PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA

LXVII – **não haverá prisão civil por dívida**, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.

O STF não mais permite a prisão do depositário infiel. Exemplo: em um processo judicial, João ajuíza ação contra José, discutindo a propriedade de um veículo. Para não deixar o veículo no pátio do DETRAN, nomeia-se como depositário o José. Ao final do processo, o Juiz determina a entrega do veículo para João; contudo, ele não entrega o bem. Nesse caso, José está sendo infiel.

O caso que deu origem ao julgamento do STF sobre a impossibilidade de prisão do depositário infiel discutia se o alienante que não devolvia o carro ante o inadimplemento era depositário infiel, uma vez que há essa equiparação na lei. Equiparava-se, na verdade, para permitir a prisão. Na decisão, o STF, em observância ao Pacto de San José da Costa Rica (1979, aderido pelo Brasil em 1992), argumentou que não haverá prisão civil

por dívida, salvo inadimplemento inescusável de obrigação alimentícia. Assim, tendo em vista o caráter supralegal do Pacto, o STF firmou o enunciado:

Súmula vinculante n. 25: é ilícita toda modalidade de prisão, não interessando qual seja a forma de depósito.

Esse dispositivo constitucional (art. 5º, LXVII, CF/88) é de eficácia contida.

A norma de contida nasce com a aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral, podendo sofrer restrição, contenção ou redução.

Dessa forma, o texto constitucional foi restringido pelo Pacto de San José da Costa Rica e não pode mais aplicar a prisão civil.

Logo, a prisão do depositário infiel não se tornou inconstitucional, pois está prevista na CF/88, não podendo apenas ser aplicada.



25m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
